

1005461-69.2018.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Andre Salomon Tudisco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 05/03/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit.).
De igual forma, não subsistem argumentos sobre a anulação do contrato de franquia. Não foi alegada qualquer causa de sua anulação. Os requerente alegam, em verdade, fatos que ocorreram na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

1005461-69.2018.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005461-69.2018.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente:

Anju Tecnologia e Consultoria Ltda e outros

Requerido:

10FC Marketing Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Salomon Tudisco

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por ANJU TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, JUAN CAIO DO ESPÍRITO SANTO ROCHA e DIANA ROCHA DO ESPÍRITO SANTO contra 10FC MARKETING EIRELI (FRANQUIA PAGPOUCO/ZUKKIN). Os autores firmaram contrato de franquia com a ré para que atuassem como franqueados/consultores da PAGPOUCO. Iniciadas as atividades, alegam que o treinamento oferecido pela franqueadora foi passado de forma superficial, que o modelo de negócio não foi adaptado de acordo com as características de sua região em que atuam e que as expectativas de faturamento tinham como referência o mercado consumidor e varejista da grande São Paulo e não sua região, interior de Minas Gerais. Afirmam que, com o passar dos meses, os problemas com a franqueadora só aumentaram e que em março de 2017 o sistema parou de funcionar corretamente, permanecendo assim ao menos por algumas semanas. Diante destas circunstâncias, requerem a resolução contratual, sendo autorizada a compensação, no caso de algum valor devido pelos autores, se assim apurado em liquidação, ou, subsidiariamente, a declaração de anulação do contrato de franquia com a devolução de tudo que já tenha sido pago, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes e perda de uma chance, ao pagamento de multa contratual e danos morais no valor de R\$ 30.000,00. Concessão do benefício à justiça gratuita e indeferimento do pedido de tutela antecipada (fls. 517/518).

Designação de audiência de conciliação (fls. 522/524), que restou prejudicada diante da ausência da requerida (f. 528).

Sentença que reconhece a revelia da requerida, lhe aplicando multa de 2% do valor corrigido da causa e julgando os pedidos procedentes em parte, declarando rescindido o contrato por culpa da ré e condenando-a ao pagamento de multa contratual (fls. 531/538).

A requerida apresentou razões de apelação (fls. 540/591). Preliminarmente indica nulidade da citação, tendo em vista que fora encaminhada ao domicílio antigo da empresa, havendo comprovação de que os requerentes tinham ciência da mudança. No mérito, indica que os documentos colacionados indicam que a COF não padece de irregularidades e que a franqueadora prestou total suporte à franqueada, sendo a presente ação movida por mera insatisfação dos autores. Nesse contexto, requerem a anulação da sentença em razão da ausência de citação, a concessão de prazo para instrução processual e a condenação dos autores por litigância de má-fé.

Subsidiariamente, pleiteia a improcedência da demanda, afastando a condenação do pagamento de multa por inadimplemento contratual.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 658/665).

Decisão monocrática com anulação da sentença de fls. 531/538, diante do reconhecimento de vício na citação.

Embargos de declaração contra a decisão monocrática exarada no recurso de apelação, em que se alega omissão e contradição (fls. 679/683).

Intimada para resposta, a embargada apresentou contrarrazões (fls. 678/690).

Acolhimento parcial dos embargos para o conhecimento de omissão seguida de anulação da decisão monocrática a fim de que a análise do recurso seja feita pelo órgão colegiado (fls. 691/694).

Foi proferido acórdão, que manteve o entendimento da decisão anulada, reconhecendo o vício da citação e a nulidade da sentença, ocasião em que foi determinado o retorno dos autos à Vara de Origem, com reabertura de prazo para apresentação de contestação (fls. 698/704).

Cumprido o v. Acórdão, a requerida apresentou contestação (fls. 706/743) alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo de Santos, diante da cláusula de eleição de foro. No mérito, alegam que a COF esclarecia, à época da contratação com os autores, que o negócio seria inicial e, portanto precário, tratando-se de uma tecnologia nova e que não haveria comprovação de seu sucesso. Sustenta que sempre deixou claro aos autores que a franquia ainda não possuía atividade quando da contratação, todos estes fatos de amplo e inegável conhecimento dos autores. Alega, ainda, que as dificuldades de coleta de dados experimentadas pelos autores não são sua responsabilidade, apontando que uma das cláusulas do contrato deixa claro que os franqueados deverão se comprometer em coletar e atualizar os preços de sua região, independentemente das dificuldades relatadas. Quanto à alegação de ausência de treinamento e de prestação de assistência, nega a ocorrência, inclusive afirmando que os autores se consideravam satisfeitos na época do ocorrido, conforme e-mails que junta aos autos.

Sobreveio réplica (fls. 777/790).

Instados sobre as provas que desejavam produzir, os autores e os réus postularam a produção de prova testemunhal (fls. 798/802 e 795/797).

Decisão em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 845/852, determinando a redistribuição da ação à Vara do Foro Central da Capital (fls. 857).

Decisão determinando a redistribuição às Varas Empresariais (fls. 861).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, porque inexistente a necessidade de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É o caso de improcedência dos pedidos autorais.

Por determinação do art. 2º da Lei nº 8.955/94, "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e

administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181). Foram apontadas na inicial, como descrito no relatório, as seguintes condutas supostamente irregulares da requerida:

I- Treinamento oferecido pela Franqueadora teria sido superficial

II - Modelo de negócio não foi adaptado de acordo com as características da região franqueada

III - As expectativas de faturamento tinham como referência o mercado consumidor e varejista da grande São Paulo e não sua região, interior de Minas Gerais e

IV - Recusa de diversos mercados da região à coleta de dados e ausência de intervenção da requerida

A alegação de que o treinamento da franqueadora teria sido superficial e, portanto, insuficiente para que operassem, não possui lastro probatório.

Os autores apenas alegam (fl.7) que o treinamento foi superficial e realizado em tempo muito curto. Todavia, em continuidade a suas próprias declarações, informam que a requerida demonstrou habilmente como funcionária a coleta de dados e realizou treinamentos básicos.

Todavia, em e-mail enviado pelo autor à requerida (fl. 720) consta o relato de que este não realizou o último dia de treinamento, mas sinalizou que "o treinamento foi excelente, superou muito as expectativas". De igual forma, o e-mail de fl.720 contém o seguinte relato sobre o treinamento: "Ficamos muito felizes" Mais aprendizados gerais para todos!".

Como se observa, há contradição entre o que dito à época e o relatado na petição inicial. Ausentes provas sobre tal alegação, tem-se que não deve ser acolhida.

Quanto às alegações de que o modelo de negócio não teria sido adaptado à região, pela requerida, expectativa de faturamento irreal e problemas no sistema de banco de dados, estas também são desacompanhadas de provas.

Como dito pela requerida em sua contestação, a COF, de fato, aclara que o franqueamento apenas se iniciou no final do ano de 2016, ou seja, na mesma época que realizado o contrato com os autores.

Às fls. 135 consta a informação de que havia apenas 4 franquias operantes à época o que, sabidamente, não representa número expressivo para que se tenha qualquer promessa de sucesso. De igual forma, as fls. 112/113 dizem expressamente que os dados financeiros apresentados se tratam de meras projeções, por se tratar de atividade e tecnologia nova, sem comprovação de sucesso.

Por óbvio que ninguém ingressa em franquia sem que se tenha mínimas expectativas de lucratividade, todavia, ingressando logo no início as operações, as taxas de aquisição e cobranças costumam ser inferiores as que venham a ser praticadas no futuro, caso a franquia prospere.

Trata-se, portanto, de risco do negócio, assumido espontaneamente pelos autores.

Quanto à ausência de marca pela requerida, também não se observa a procedência de

tal alegação.

Ainda que, de fato, a requerida não tenha logrado êxito na obtenção da marca perante o INPI, o que foi confirmado apenas anos após os fatos aqui relatados, não teria sido esta a razão para que os requerentes experimentassem insucesso em suas operações.

Por fim, a recusa de ingresso dos autores nas dependências dos mercados da região não gera culpa à requerida. Em que pese a alegação de que esta poderia ter auxiliado os autores, o contrato é expresso em atribuir ao franqueado a responsabilidade por obtenção dos dados.

Portanto, há que se reconhecer a improcedência do pedido de rescisão do contrato de franquia por justa causa da franqueadora, bem como o pedido alternativo de anulação do contrato, visto que as alegações que os fundamentam não encontram lastro no conjunto probatório acostado aos autos.

A propósito disso, observo que, sobre a rescisão por justa causa, o contrato de franquia estipulou no § único da Cláusula nº 34 que, "Na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato, a parte que se sentir prejudicada deverá notificar a outra para que cesse a prática violadora em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ficar configurada justa causa para rescisão do presente contrato. Não sanada a prática violadora até a data aprazada, a parte que preferir dar por rescindida a contratação deverá enviar à outra nova notificação fixando o termo final do contrato como sendo o 5º dia útil subsequente ao seu recebimento, sendo que, nessa hipótese, a parte que deu causa à rescisão ficaria obrigada, segundo o caput da Cláusula nº 36, ao pagamento de "multa de 10 (dez) vezes o valor da taxa de franquia para a parte que infringir, no todo ou parcialmente, pela terceira vez, seguida ou alternadas, depois de devidamente notificado do ato, qualquer das cláusulas deste instrumento, reservando-se à parte inocente o direito de, simultaneamente, considerá-lo automaticamente rescindido (...)" (fls. 198/200).

Vê-se, portanto, que as partes pactuaram que, as eventuais práticas violadoras de obrigações contratuais deveriam ser objeto de notificação para a cessação da prática antes que aplicável a pena de rescisão do contrato por justa causa.

Assim, em que pese as alegações e documentos trazidos pelos autores, estes, por si só, não são suficientes para evidenciar a justa causa para rescisão do contrato por culpa da franqueadora. Tratou-se, portanto, de rescisão unilateral promovida pelos autores, que cessaram as atividades franqueadas.

Outrossim, subsistindo a rescisão imotivada, há que ser julgada improcedente a demanda da franqueada quanto à condenação da franqueadora ao pagamento da multa contratual e danos materiais, tanto a título de lucros cessantes quanto sobre a perda de uma chance.

Como dito acima, nenhuma das alegações da autora é causa direta para a rescisão por justa causa e seria necessária a notificação da requerida para, primeiramente, corrigir a falha de seu serviço para, somente após, ser alegado o descumprimento contratual, o que não ocorreu.

Há nos autos apenas uma contranotificação dos autores que, conforme relatam, foi realizada após o encerramento de suas operações (fls. 215/216) e, portanto, seria insuficiente para atestar a culpa da ré no descumprimento de qualquer obrigação contratual.

A propósito, observa-se que o contrato pactuado entre as partes tem natureza empresarial. E, como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o pacta sunt servanda, a Professora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua

ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit.).

De igual forma, não subsistem argumentos sobre a anulação do contrato de franquia. Não foi alegada qualquer causa de sua anulação. Os requerente alegam, em verdade, fatos que ocorreram na constância do contrato, não havendo qualquer indicação de dolo, fraude, coação ou qualquer outra razão que ensejasse a anulação do contrato. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sucumbente, condeno os autores nas custas e despesas processuais, bem como honorários dos patronos do réu, os quais fixo em 10% do valor da causa atualizado. P.R.I.C

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.